

1501512-45.2021.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/07/2022

... HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CRIME DE MERA CONDUTA. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. GUARDA MUNICIPAL. ESTADO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA. ART. 301 DO CPP. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos delitos de mera conduta, aí incluídos o tráfico e a guarda de substância entorpecente, não é necessário resultado decorrente da ação ou omissão, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501512-45.2021.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2310684/2021 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 21395397 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2703/21/609 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2310684 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

RAFAEL VIEIRA BARBOSA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Data da Audiência:

07/07/2022

Em 07 de julho de 2022, às 13:30h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. Drª MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MMª Juíza de Direito Titular, comigo Assistente Judiciário ao final nomeado, pela MMª Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: o representante do Ministério Público, na pessoa do Dr. Carlos Eduardo Pozzi, DD. Promotor de Justiça da Comarca de Tatuí, o réu RAFAEL VIEIRA BARBOSA, bem como o seu Defensor Técnico, Dr. Mateus Soares, OAB 283788/SP. Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual as testemunhas arroladas em comum pelas partes, Kaique dos Santos Dias, Eduardo Leopoldo Ambold e Ademir José Vicente. INICIADOS OS TRABALHOS, possibilitou-se que o Defensor se entrevistasse reservadamente com o acusado. Em seguida, passou-se à oitiva das testemunhas acima mencionadas, passando-se, então, ao interrogatório do réu. Nada obstante o encerramento do Sistema Remoto de Trabalho e do Sistema Escalonado de Retorno ao Trabalho Presencial, a presente audiência foi realizada por meio de videoconferência, através da plataforma Microsoft Teams, conforme disciplina já estabelecida pela Corregedoria Geral da Justiça no Comunicado CG nº 284/2020 (cf. artigo 8º do Provimento CSM nº

2651/2022). Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo, com a posterior importação dos arquivos no sistema informatizado SAJPG5. Na sequência, pela MMª Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. O réu RAFAEL VIEIRA BARBOSA, devidamente qualificado nos autos, imputando a ele a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, eis que, no dia no dia 15 de novembro de 2021, por volta das 15h, na Rua Antônio Carlos da Silva, nº 165 - Thomas Guedes, nesta cidade e Comarca de Tatuí, guardava e tinha em depósito, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 112 porções de "crack", subproduto da cocaína, com peso bruto aproximado de 26,3 gramas,, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo consta da denúncia, na data dos fatos, o acusado se dedicava ao tráfico ilícito de drogas e, para tanto, fazia uso do imóvel em que residia, onde guardava e mantinha grande quantidade de "crack" em depósito, para posterior entrega ao consumo de terceiros. Guardas Civis Municipais estavam em serviço quando receberam delação anônima dando conta de que um indivíduo conhecido como "irmão chocolate" estaria a bordo do veículo VW/GOL, Placas DBZ-3430, levando drogas para a residência de RAFAEL, localizada na Rua Antônio Carlos da Silva, nº 165. De imediato, os guardas se deslocaram para o Bairro Thomás Guedes, com vistas a localizar o veículo e a residência mencionada e, ao ganharem a Rua Antônio Carlos da Silva, se depararam com RAFAEL, que estava na via pública, parado em frente ao imóvel. Ao perceber a aproximação da viatura, o acusado demonstrou atitude evasiva e correu para dentro de sua casa, sendo então abordado. Na residência do réu, os guardas encontraram Kaique dos Santos Dias, que estava ali, segundo declarou, para pegar fraldas emprestadas e declarou a tudo desconhecer. Na ocasião, indagado, RAFAEL admitiu a prática delitiva e indicou o local onde guardava os entorpecentes. Assim é que, no telhado, os Guardas lograram encontrar 8 "kits", cada um contendo 112 porções de "crack", individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas, drogas que pertenciam a RAFAEL e estavam destinadas à venda. Dando continuidade às diligências, os Guardas Civis ainda encontraram 1 aparelho de telefone celular e 1 caderno contendo anotações alusivas ao tráfico de drogas, bem como a importância de R\$ 204,00 em espécie, dentro do caderno localizado, dinheiro angariado com a venda de drogas que o acusado promovia naquele local. O réu foi notificado (fls. 120) e apresentou Defesa Preliminar (fls. 125/171). Assim, por decisão proferida no dia 05 de julho de 2022, foi recebida a denúncia (fls. 175/179). Durante a instrução, foram ouvidas três testemunhas, ultimando-se com o interrogatório do réu, tudo gravado em audiovisual. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação do acusado nos exatos termos da Denúncia, enquanto a Defesa Técnica, de outro lado, pugnou pela absolvição do réu, sustentando insuficiência probatória, bem como, subsidiariamente, a desclassificação delitiva e, finalmente, em caso de condenação, pela incidência de todas os benefícios legais cabíveis a incidir em dosimetria da pena e na fixação do regime prisional inicial. Certidões a fls. 18/19 e 187/188. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO e Decido. PRELIMINARMENTE, faz-se necessário salientar que operação levada a cabo pelos agentes públicos em comento atendeu aos requisitos legais, não violando preceito constitucional ou abrigado em Lei. Ora, a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Ora, distintamente do alegado pelo D. Defensor, os guardas civis municipais, no momento em que notaram o estado flagrancial, não estavam efetuando diligências para investigações preliminares, mas sim realizando patrulhamento rotineiro para prevenir e inibir ações criminosas contra o patrimônio público municipal, atribuição esta lhes conferida por lei ordinária (art. 5º, II, da Lei nº 13.022/2014), a qual regulamentou a competência atribuída em nossa Carta Magna a esta corporação (art. 144, § 8º, da CF). Faz-se mister ressaltar, outrossim, que os guardas civis municipais não extrapolaram suas funções.

Deveras, se presente o estado de flagrância delitiva, a atuação de “qualquer pessoa do povo” seria legal, de acordo com a previsão legal insculpida no art. 301 do Código de Processo Penal. Por tal razão, não há óbices para a ação dos guardas civis municipais, os quais, por serem agentes de segurança, não devem se manter inertes diante de patente atividade criminosa. Neste sentido, coleciono o seguinte julgado: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CRIME DE MERA CONDUTA. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. GUARDA MUNICIPAL. ESTADO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA. ART. 301 DO CPP. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos delitos de mera conduta, aí incluídos o tráfico e a guarda de substância entorpecente, não é necessário resultado decorrente da ação ou omissão, bastando a simples conduta para a constituição do elemento material da figura típica penal, o que afasta a dúvida sobre o estado de flagrância delitiva do recorrente. 2. Dessa forma, à luz do art. 301 do CPP, “qualquer do povo” poderia ter efetuado sua prisão em flagrante, aí incluídos os agentes públicos da guarda municipal. 3. Afastada qualquer ilegalidade na custódia provisória decorrente de flagrante delito, afastado está o seu relaxamento. 4. Recurso a que se nega provimento. (STJ - RHC: 17645 SP 2005/0066036-6, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 06/09/2005, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 26/09/2005 p. 408) (grifos aditados). Acrescente-se que até mesmo o legislador ordinário acolheu este entendimento, pois no art. 5º, inciso XIII, da Lei nº 13022/2014, atribuiu a Guarda Civil Municipal a competência de “garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas”, consolidando o entendimento jurisprudencial acima exposto. Ainda sobre a desnecessidade de mandado de busca domiciliar decorrente do estado de flagrância pela natureza do delito em espécie, segue a jurisprudência - EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. REITERAÇÃO PARCIAL DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Parte do objeto deste writ já foi apreciado por esta Suprema Corte nos autos do HC 199.091/RJ. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de pedido anterior. Precedentes. 3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 5. Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, RHC 213852 AgR, Relator(a) Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Julgamento: 30/05/2022, Publicação: 01/06/2022). Vencida a questão preliminar arguida, passo ao exame da matéria meritória. Pois bem, o pedido ministerial comporta procedência, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito,

que se configurou consumado, não havendo dúvidas quanto à autoria, bem patenteada a tipicidade da conduta. De fato, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), pelo auto de constatação preliminar (fls. 11), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 50/53) e, finalmente, pela contundente prova oral produzida. A autoria é igualmente evidente e clara. Vejamos: O réu, em solo policial (fls. 05), afirmou que a droga encontrada na sua casa é sua e que Kaique é seu amigo. Kaique foi na sua casa para pegar fralda para o filho dele. Possui filho pequeno (um filho de 2 anos e uma menina de 6 meses) e iria emprestar fralda para Kaique. Afirmou que Kaique não vende drogas. Confessou que estava vendendo cada porção do crack por dez reais. Disse que está desempregado

faz 4 meses, que estava trabalhando na Cerâmica Souza Tec e entrou no tráfico para sustentar sua família. Em juízo, disse que no dia dos fatos Kaique foi em sua casa para pegar fralda para seu filho e quando entrou para pegar a fralda a polícia chegou ao local. Nem conhece este tal de Chocolate. Estava devendo para uma pessoa que lhe deu 15 dias para pagar, caso contrário ele lhe mataria. Foi até a cerâmica, conversou com Roberto e pegou droga para vender. Roberto trabalha na cerâmica, ele é caminhoneiro. Disse para os policiais que a droga estava no telhado. Esta preste por tráfico. Tem 19 anos. Teve passagem na fundação casa por tráfico. É caso e tem dois filhos. Estava devendo a quantia de R\$1500,00. Agora ficou devendo mais ainda. Pegou emprestado dinheiro do cigano Luiz. Essas guardas municipais toda vez que o pegavam o agrediam. Já lhe bateram até na frente de sua mulher. Já levou mais de 20 tapas na cara na frente de seu filho. Os guardas não tinham mandado. Analisando a autodefesa do acusado - colhida com máxima observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa - observo que o acusado confessou os fatos, o que foi corroborado pela prova oral produzida. De fato, o Guarda Civil Municipal Eduardo Leopoldo Ambold, em sede policial (fls. 02), relatou que, na data dos fatos, juntamente com seu colega de corporação, estavam em patrulhamento quando receberam uma denúncia anônima que um sujeito conhecido pelo vulgo "irmão chocolate" (identificado posteriormente Jair Nunes de Oliveira), que seria o gerente do tráfico de drogas no bairro Tomas Guedes, estaria dirigindo um veículo Gol de cor prata placa DBZ 3430, oportunidade em que estaria levando drogas para a residência de um indivíduo de nome Rafael, vulgo neguinho. Desceram em patrulhamento em conjunto com a viatura do Canil no bairro Tomas Guedes para localizar o veículo e a casa de Rafael. Entraram na rua Antonio Carlos da Silva, oportunidade em que o acusado estava na frente de sua casa. O réu, ao avistar a viatura, empreendeu fuga para dentro de sua casa. Desembarcaram e conseguiram detê-lo dentro da casa, onde também se encontrava o sujeito de nome Kaique. Indagado, o acusado falou que realmente estava traficando drogas e indicou que possuía 8 kits de crack em cima do telhado de sua casa. Subiu no local indicado e localizou o total de 112 porções de crack. Na casa, seu colega de farda Ademir localizou o aparelho celular de RAFAEL e um caderno com duas folhas de anotações. Dentro desse mesmo caderno, foi localizado R\$ 204,00 em dinheiro. RAFAEL confessou que o dinheiro era da venda de drogas e as anotações seria referente ao tráfico de drogas que ele realiza. Indagado, Kaique falou ser amigo de RAFAEL e estava ali para comprar fraldas. Em juízo, confirmou os fatos já declarados em solo policial, que o réu Rafael admitiu o comércio, apontou uma escada que dava para o telhado e ali foram encontrados os kits de crack. Na casa ainda foi encontrado um caderno com anotações e dinheiro. Na casa não foram encontrados apetrechos para o uso da droga e o réu não aparentava estar sob efeito de substância entorpecente. Convergingo em mesmo sentido, o também Guarda Civil Municipal Ademir José Vicente, em sede policial (fls. 04), corroborou integralmente a versão de seu colega de trabalho. Em juízo, disse que estavam em patrulhamento próximo pelo bairro Thomas Guedes quando um mototaxista acenou para eles e disse que o indivíduo Chocolate, a bordo de um gol prata, iria entregar droga para Rafael para ser vendido no bairro Thomas Guesdes. Foram no encalço, sendo que já conheciam Rafael. Na casa de Rafael estava a pessoa de Kaique. Indagado Rafael confessou o tráfico de entorpecentes, que foi encontrado no telhado. No quarto do réu ainda tinha anotações e dinheiro. Tinha coisas de criança na casa de Rafael e salvo engano ele tinha uma criança pequena. Perguntas da defesa- o denunciante disse que Rafael estava em frente da residência dele. Já participou da apreensão do réu quando menor. Também há várias denúncias no bairro acerca de Rafael. Fazem ronda em toda cidade, mas dão preferência para o local em que já denuncia. O réu disse que não usa crack, não tinha apetrechos para o uso e o réu não aparentava estar sob efeito da droga. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos agentes de segurança, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos guardas, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente o réu ou faltar com a verdade. Por tais

razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Neste sentido: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu. Validação Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu. Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuarão a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP - APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifos aditados). Finalmente, a testemunha Kaique dos Santos Dias, em solo policial (fls. 02), afirmou que é colega de RAFAEL, que mora lá perto. Foi lá na casa dele para pegar fralda. Não estava vendendo drogas. Sua criança tem 7 meses e já emprestou fralda dele algumas vezes. Trabalha na grameira Vioto há 1 mês. Não sabia nada sobre as drogas. Em juízo, disse que é colega de vizinhança. No dia dos fatos foi até a casa de Rafael pegar uma fralda emprestada, pois sabia que ele tinha uma criança, nisso chegou um monte de polícia no local. Não conseguiu pegar a fralda. Não presenciou a ocorrência, pois eles o colocaram num canto da parede e ficaram conversando com Rafael. Não sabe dizer se os guardas tinham algum mandado. Não viu os guardas encontrarem a droga ou subirem no telhado. Não sabe dizer se Rafael vende entorpecente pois trabalha durante o dia. Examinando o arcabouço probatório emergente dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração do crime de tráfico de entorpecentes. Ora, é inequívoco que o acusado guardava e mantinha em depósito substâncias entorpecentes, conforme: 1) os coerentes e insuspeitos depoimentos dos Agentes Públicos, que narraram verossimilmente, a apreensão das drogas na casa do réu; 2) o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 50/53), o qual atestou que a substância apreendida era entorpecente; e 3) a admissão do réu, de que as drogas lhe pertenciam. Igualmente indisfarçável é a finalidade mercantil da droga, a despeito da não flagrância de ato de mercancia de narcóticos. Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal retro mencionado reste configurado. Estabelecida esta premissa e escorada na previsão legal contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo do réu de traficar a droga apreendida. Com efeito, tem-se: 1) a quantidade de narcóticos apreendidos; 2) sua forma de embalagem, em pequenas frações e forma de acondicionamento própria para a venda "a varejo" de entorpecentes; 3) a não apreensão de qualquer instrumento ou apetrecho utilizado para o consumo das drogas; 4) o comportamento suspeito do acusado, o qual, ao notar a viatura, empreender fuga; 5) a localização de anotações referentes à contabilidade do tráfico na residência do réu; e 6) a confissão do acusado. Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da lavra do Des. Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte: "Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era "ponto de tráfico" e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de "cocaína" em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo "ependorf" de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes

praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da “cocaína” em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, apreendidas 3,2 gramas da droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao usuário. Até porque o uso continuado de “cocaína” provoca o “enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação” (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não ser indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654; RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). Para Fernando de Almeida Pedroso, “em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo” (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96) Nessa linha de entendimento, é a jurisprudência atualmente majoritária (cf., verbi gratia, RTJ, 149/521; RSTJ, 142/454 e 169/499; RJTJERGS, 177/57; LexJTJ, 165/334, 170/288, 174/333, 180/284, 186/305, 205/314, 208/272 e 277/523; RT, 537/335, 675/406, 714/357, 718/394, 727/478, 729/542, 737/684, 739/639, 740/634, 747/642, 776/663, 779/554, 789/536, 793/576, 793/727, 800/597, 801/606, 807/597, 832/588. Portanto, provado que se faz presente a elementar do tipo substância entorpecente (laudo de exame químico-toxicológico a fls. 50/53) e demonstrado que o réu incorreu em verbos nucleares contidos no artigo 33, caput, da Lei 11343/06 – trazer consigo –, fazendo-o com a inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo legal retro mencionado. Certo, portanto, que o réu perpetrou o crime de tráfico de entorpecentes, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o jus puniendi, razão pela qual passo a dosimetria da pena a ser lhe imposta. Observando as diretrizes gerais, traçadas no artigo 59 do Código Penal, e as específicas, dispostas no artigo 42 da Lei 11.343/2006, verifico que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis. Isso porque, a despeito de contar com condenação criminal provisória (fls. 187/188), tem-se que essa se refere a fato posterior ao que se julga in casu. E, portanto, não pode ser valorado negativamente na primeira fase de dosimetria da pena. Nesse sentido: “Impossibilitada a aplicação de antecedentes criminais relativos a infrações praticadas após àquela objeto da denúncia. Precedentes” (STJ. 5ª Turma. HC n. 268.762/SC, Min. Regina Helena Costa, DJe 29/10/2013). Até porque, pela não definitividade desse apontamento, é insusceptível de valoração negativa nessa fase da dosimetria da pena, nos termos da Súmula nº 444 do STJ (“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”). Desse

modo fixo a pena-base do acusado no mínimo legal, qual seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Em segunda fase, embora o réu seja menor de 21 anos à época dos fatos e sua confissão espontânea tenha embasado a prolação desse édito condenatório (Súmula nº 545 do C. STJ), deixo de aplicar as atenuantes de menoridade relativa e confissão, pois a pena-base fora fixado no mínimo legal, piso abaixo do qual não se pode reduzir a pena nessa fase (Súmula nº 231 do C. STJ). Mantenho, pois, sua pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a qual torno definitiva, ante a míngua de causas modificadoras da pena a incidir. Convém destacar a inaplicabilidade da agravante do estado de calamidade pública. Ora, não há provas de que o acusado se valeu das fragilidades proporcionadas pela situação calamitosa ou que agravou esse estado. Assim, imperioso o afastamento da agravante postulada pelo Parquet. Aliás, assim se posiciona a jurisprudência: "Contudo, entendo que a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, relativa ao estado de calamidade pública, deve ter na sua incidência relação com o contexto do delito e a desproteção do bem jurídico tutelado pelo tipo penal. No entanto, no caso em apreço, entendo não comprovada relação direta entre o cometimento do delito e a emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus (declarada pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020), de modo que o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, em razão do crime ter sido praticado durante estado de calamidade pública, deve ser afastado. Note-se que não há qualquer evidência nos autos de que o estado de calamidade tenha facilitado a ação criminosa, de que o apelante tenha se aproveitado dessa situação excepcional para perpetrar o delito ou, ainda, de que o crime tenha sido mais grave por ter ocorrido durante a pandemia" (TJSP; Apelação Criminal 1501673-18.2020.8.26.0530; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021). A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é inaplicável ao caso sub judice. De fato, a incidência dessa benesse legal reclama a presença simultânea de 04 requisitos subjetivos, a saber, primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades delitivas e não integração a organização criminosa. In casu, trata-se de réu que desde sua infância envereda-se pelo caminho da delinquência (fls. 19) e está sendo processado em outro feito (fls. 187/188), inclusive foi condenado provisoriamente pelo mesmo crime que se apura nos autos por fatos ocorridos poucos meses após a libertação operada em seu benefício nesses autos. E, portanto, tem-se sua dedicação a atividades criminosas, restando inviabilizada a concessão da benesse em questão. A propósito, assim se posiciona a jurisprudência do C. STJ: "É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006." (STJ. 3ª Seção. EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 14/12/2016). Mas não é só! Robustecendo a certeza de dedicação do réu a atividades criminosas, tem-se a apreensão de anotações da traficância, indicando reiteração da mercancia (fls. 80/84), bem como a considerável quantidade de drogas apreendidas, revelando o caráter não episódico da traficância. Em síntese, todos esses elementos indicam reiteração do tráfico e, portanto, dedicação do réu à atividades criminosas, afastando a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Aliás, assim também se posiciona a jurisprudência, entendendo que os elementos acima expostos são idôneos a indicar dedicação à atividades criminosas e afastar a figura do tráfico privilegiado: "6. A Corte Estadual, para manter o não reconhecimento do tráfico privilegiado, amparou-se na conclusão de que os Recorrentes agiram de forma organizada e, apesar de o fato de as drogas apreendidas serem bastante nocivas não justificar, por si só, a conclusão pela dedicação às atividades criminosas, foram utilizados outros elementos concretos para demonstrar a atuação dos Recorrentes em atividades criminosas, tais como: a quantidade de droga apreendida, a apreensão de balanças de precisão, as grandes quantidades de eppendorfs e saquinhos para confecção das porções, o valor de R\$ 1900,00 e o caderno de anotações da contabilidade dessa atividade. Portanto,

é idônea a fundamentação utilizada para negar a minorante." (REsp n. 1.978.262/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022). Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal e, com fundamento nos artigos 33, § 3º, c/c o artigo 59, inciso III, todos do Código Penal, determino que o réu inicie o cumprimento da pena no regime fechado, considerando seu histórico infracional (fls. 19) e a personalidade do acusado (condenado provisoriamente por tráfico por fatos ocorridos poucos meses após a libertação operada em seu favor nesses autos), revelando sua forte persistência na seara criminosa e que somente o regime prisional mais severo é capaz de conter seu ímpeto criminoso. A tão só quantidade de pena inviabiliza a concessão do sursis e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o réu RAFAEL VIEIRA BARBOSA, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Defiro o Apelo em Liberdade, considerando que o acusado respondeu ao feito em liberdade (fls. 24/28) e não sobrevieram razões que exigissem sua segregação cautelar. Mas deve ser observado que o acusado está preso por outro processo. Isento o acusado do pagamento das custas processuais, concedendo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, já que assistido por Defensor Dativo. Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor total de pena de multa. Após, intime-se o réu para que efetue o pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Sem prejuízo, considerando que o entorpecente apreendido já foi periciado, destrua-se a droga na forma da lei. Como efeito da condenação, por força da regra do art. 91, II, "b", do Código Penal, c.c. art. 63, da Lei nº 11.343/06, bem como do mandamento constitucional do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, ACOLHO o pedido confiscatório veiculado na denúncia (fls. 110) e DECRETO a perda do montante apreendido (R\$ 204,00 em dinheiro - fls. 54) em favor da União, apropriados os bens ao Funad (§1º do referido art. 63), pois comprovada sua proveniência criminosa. Quanto aos demais bens apreendidos, acaso transitado em julgado e decorrido o prazo de 90 dias sem que se reclame a liberação dos demais objetos, destrua-se esses na forma do que preceitua os arts. 123 e 124, ambos do CPP. Pelo Defensor do(a) réu e pelo(a) réu foi manifestado o interesse em interpor recurso. Pela MM. Juíza de Direito foi dito: "RECEBO o recurso interposto pelo(a) réu, saindo o Defensor, desde já, intimado a apresentar razões de recurso, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena de destituição e nomeação de novo Defensor. Após apresentadas as razões, expeça-se a competente Certidão de Honorários. Com a vinda das contrarrazões remetam-se os autos à superior instância com as cautelas de praxe". Com o trânsito em julgado da condenação criminal, lance-se o nome do(a) réu no rol dos culpados. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Alisson Eduardo de Oliveira, Assistente Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA